



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2013.0000299873

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0016381-42.2008.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante RUBENS SILVA E OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para, afastada a incidência do art. 9º, da Lei nº 8.072/90, reduzir a pena de RUBENS SILVA DE OLIVEIRA para quinze anos de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Esgotadas as vias impugnativas, expeça-se mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.

São Paulo, 23 de maio de 2013.

Ericson Maranhão
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

ATENTADOS VIOLENTOS AO PUDOR – Materialidade e autoria comprovadas – As palavras das vítimas têm força probante indiscutível, sempre que firmes, coerentes e amparadas nos demais elementos probatórios – Negativa do réu que não encontrou amparo no conjunto probatório coligido – Condenação mantida.

PENAS – Adequação – Básicas que devem retornar aos patamares mínimos porque a fundamentação utilizada para a majoração refere-se a circunstâncias que integram o tipo penal - Afastamento da causa de aumento do art. 9º, da Lei nº 8.072/90, em razão da revogação do art. 224, do Código Penal, pela Lei nº 12.015/09, ao qual fazia expressa remissão.

CUSTAS JUDICIAIS – Condenação que decorre de expressa previsão legal – Réu que, se for o caso, pode se beneficiar do artigo 12, da Lei nº 1.060/50, na execução.

Recurso parcialmente provido.

1.- RUBENS SILVA DE OLIVEIRA foi denunciado por incurso no art. 214, c.c. os arts. 224, alínea “a” e 225, § 1º, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes.

A respeitável sentença de fls. 124/129, relatório adotado, proferida pelo magistrado Fernando Luiz Batalha Navajas, condenou-o a trinta anos de reclusão, em regime fechado, por incurso no art. 213, *caput* (com a nova redação dada pela Lei nº 12.015/09), c.c. o art. 226, II, nos moldes do art. 71, todos do Código Penal, e art. 9º, da Lei nº 8.072/90.

Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por insuficiência de prova, alegando que seus filhos foram induzidos por sua ex-esposa, que pretendia vingar-se dele, em razão da separação conflituosa que tiveram. Afirma, ainda, que o laudo de fls. 18 e 19 deixa claro que não havia indícios comprobatórios da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

ocorrência dos delitos. Subsidiariamente, pugna pela redução das penas, “garantido o seu direito de recorrer em liberdade”, bem como pela concessão da justiça gratuita (fls.138/166).

Recurso bem processado, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento parcial, apenas para afastar a causa de aumento de pena em face do art. 9º, da Lei 8.072/90.

É o relatório.

2.- Primeiramente, observo que o Apelante está solto, aguardando o julgamento do presente recurso, pois o magistrado de primeiro grau, fundamentadamente, concedeu-lhe esse direito (fls. 129). Portanto, não há falar-se em garantia do apelo em liberdade.

No mais, ao contrário do sustentado pela defesa, a prova é conclusiva e firme no sentido de demonstrar a procedência da acusação.

Consta da denúncia que, em dia, horário e local incertos, mas anterior ao dia 21 de outubro de 2008, na rua 1, s/nº, Parque das Indústrias, Comarca de Sumaré, o Apelante constrangeu *Nicolas Gasparotto de Oliveira*, mediante violência presumida, a praticar ou permitir que com ele se praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Consta, ainda, que em dia, horário e local incertos,
Apelação Nº 0016381-42.2008.8.26.0604 - Sumaré



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

mas anterior ao dia 21 de outubro de 2008, no mesmo local acima mencionado, o Apelante constrangeu *Irvin Gasparotto de Oliveira*, mediante violência presumida, a praticar ou permitir que com ele se praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Segundo apurado, **RUBENS** foi casado com a genitora das vítimas durante oito anos e estavam separados há quatro anos. Desde a separação, os filhos do casal, a cada quinze dias, passavam o final de semana com o pai, ora Apelante, oportunidade em que este costumava masturbá-los, sendo que em certa ocasião, tentou fazer com que seu filho *Irvin* colocasse o pênis em seu ânus. Os fatos vieram à tona durante um diálogo onde *Irvin*, com doze anos de idade, e *Nicolas*, com oito anos de idade, contaram para a mãe que o pai os molestava sexualmente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência e pela prova oral colhida.

Irrelevante que os laudos de exame de corpo de delito tenham resultado negativo (fls. 18 e 19). Trata-se de atentado violento ao pudor, que nem sempre deixa vestígios.

A autoria é indubitosa.

O Apelante negou os crimes nas oportunidades em que ouvido. Disse que depois da separação, a mãe dos meninos passou a manipulá-los e a colocar obstáculos às suas visitas (fls. 22/23 e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

86/89).

A autoria consubstancia-se nas palavras das vítimas, que, apesar da pouca idade e do tempo decorrido desde a data dos fatos e até a tomada de seus depoimentos em juízo, apresentaram relatos coerentes, não havendo razão para duvidar-se de suas narrativas, não se comprovando tivessem qualquer motivo para acusar falsamente o próprio pai de tão grave delito (fls. 26, 27, 71/75 e 76/80).

Ninguém ignora o valor da palavra da vítima para o esclarecimento de crimes dessa natureza. Afirma-se, e com todo acerto, que ela tem valor decisivo, desde que, harmônica e coerente, tenha suporte em outros elementos probatórios. É o que ocorre na hipótese.

A tese defensiva de ocorrência de “síndrome de alienação parental” foi bem afastada na sentença.

Não há nos autos nenhum indicativo de que as crianças tenham sofrido influência de parte da genitora capaz de comprometer a validade de seus depoimentos. Como bem observado pelo douto magistrado: *“Pelo contrário, as vítimas apresentaram considerável dicção e concatenação de ideias quando ouvidas e interesse pelos estudos, a afastar qualquer argumentação de existência de pensamentos fantasiosos e congêneres ou de alienação*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

parental.” (fls. 126).

Kátia Regina Gasparotto, em depoimentos firmes e harmônicos, corroborou a versão das vítimas. Acrescentou que, após tomar conhecimento dos fatos, passou a entender o comportamento estranho dos filhos, os quais começaram apresentar certa resistência em passar os finais de semana com o pai e, quando retornavam, ficavam agressivos, não se alimentavam direito e perdiam a vontade de ir à escola (fls. 66/70).

As testemunhas arroladas pela defesa apenas atestaram a boa conduta do réu, nada acrescentando que pudesse infirmar a segura prova acusatória (fls. 81/83 e 84/85).

Diante do apurado, a acusação é absolutamente procedente.

3.- A aplicação das penas comporta adequação.

a) A justificativa utilizada para a majoração da básica, “personalidade voltada para o desrespeito e vilipêndio da liberdade sexual alheia e do desenvolvimento pleno e sadio dos infantes”, como bem observado pelo douto Procurador de Justiça, é circunstância que já faz parte do tipo penal, razão pela qual deve ser afastada.

b) O aumento de metade pela causa de aumento de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, era de rigor, uma vez que o réu é pai das vítimas.

c) O acréscimo de dois terços por conta da continuidade delitiva foi corretamente aplicado, uma vez que os crimes ocorreram por várias vezes, ao longo de quatro anos (a partir da separação do casal, quando os filhos passaram a visitar o pai em finais de semana alternados), nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

d) Embora as vítimas fossem menores de catorze anos, o aumento aplicado por conta do art. 9º da Lei nº 8.072/90 deve ser afastado. É que a Lei nº 12.015/09 revogou o art. 224, do Código Penal, ao qual a referida causa de aumento remetia expressamente.

Aplica-se a pena-base de seis anos, vigente ao tempo dos fatos, porque mais benéfica ao réu, acrescida de metade por conta da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, resultando em nove anos de reclusão para cada delito.

A continuidade delitiva foi bem reconhecida, pois os crimes foram praticados em circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução tais, que permitem considerá-los unidade jurídica.

Assim, à pena de um deles, aplica-se o aumento de dois terços, porque foram diversos delitos, durante anos, contra duas vítimas, de forma reiterada, perfazendo a punição total de quinze anos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

de reclusão.

4.- O regime fechado foi bem justificado, sendo o único compatível com delito deste jaez.

5.- Por fim, não é caso de concessão da justiça gratuita.

A condenação ao pagamento das taxas judiciárias decorre de expressa previsão legal. O Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto cuidou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Não se pode exonerar o réu da obrigação de arcar com custas judiciais. Pode ele, porém, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 12, da Lei nº 1.060/50, o que se dará quando da execução.

6.- Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para, afastada a incidência do art. 9º, da Lei nº 8.072/90, reduzir a pena de **RUBENS SILVA DE OLIVEIRA** para quinze anos de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Esgotadas as vias impugnativas, expeça-se mandado de prisão.

ERICSON MARANHO
Relator